



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 813/2015/2/CA1

Paraná, 23 de noviembre de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidente y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. N° FPA 813/2015/2/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE AGOSTINELLI RODRIGUEZ, ALCIDES OSCAR EN AUTOS AGOSTINELLI RODRIGUEZ, ALCIDES OSCAR POR INFRACCION LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso, dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Alcides Oscar Agostinelli Rodríguez contra la resolución obrante a fs. 1/4, en cuanto decreta el procesamiento del nombrado, por el hecho por el cual fuera indagado, tenencia simple de estupefacientes, previsto y reprimido por el art. 14, 1ra. parte, de la ley 23.737, art. 45 CP y de conformidad a los arts. 306 y 308 del Cód. Proc. Penal. El recurso es concedido a fs. 10.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la



que da cuenta el acta de fs. 25 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez; y el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli, en defensa del imputado Alcides Oscar Agostinelli Rodríguez; quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I-a) Que, el Dr. Castelli indica que en la indagatoria su defendido realizó un descargo coherente, que la sustancia encontrada era para consumo personal, no hubo trascendencia a terceros.

Señala que el conductor del vehículo no tenía conocimiento de la sustancia en el bolso de su defendido, y afirma que la declaración indagatoria ampliatoria, al momento de la elevación de la causa a juicio, afectó el derecho de su defendido a obtener una resolución en un plazo razonable. Invoca "Mattei" de la C.S.J.N.

Se agravia asimismo de la calificación legal. Refiere que se trata de 3.6 gr. de marihuana y tres pastillas de éxtasis, destacando que el derrotero del muchacho da a entender que era para consumo personal. Alude al informe del médico de cámara.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 813/2015/2/CA1

Invoca los precedentes “Vega Giménez” y “Arriola” de la CSJN. Solicita se califique la conducta de su defendido conforme al art. 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 y se resuelva la atipicidad del hecho investigado.

b) A su turno, el Sr. Fiscal General, señala que el caso tiene relativa sencillez y un trámite procesal irregular. Refiere al procedimiento. Indica que el oficial interviniente señala que habría observado migajas de estupefacientes en la alfombra, y que luego -cuando fue llamado a declarar como testigo- indica lo del olor. Señala que el propio oficial con una total falta de tino normativo, le pregunta a los imputados de quién era lo encontrado; y sostiene que no puede hacerle preguntas al imputado; sin perjuicio de lo cual, el Juez lo toma como prueba. Indica que lo expuesto es un llamado de atención y que no pretende fundamentar una nulidad.

Destaca que el hecho es de febrero de 2015, y que el Fiscal pretendía una nueva causa. Aduce que el Juez llama a indagatoria ampliatoria y le atribuye lo mismo que antes, pero le agrega las pastillas. Señala que el Magistrado en vez de considerar incluido dentro del auto de procesamiento



las tres pastillas, dicta un nuevo auto de procesamiento.

Afirma que el Estado no se puede equivocar sin que esto tenga consecuencias, y que fueron el Fiscal y el Juez quienes no tuvieron en cuenta ese dato.

Indica que están dadas las condiciones para que se considere que es un caso de tenencia para consumo. Indica que se podría dudar de la trascendencia porque Alí no sabía que lo tenía.

Solicita, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se haga lugar al recurso y se valore como tenencia atenuada de estupefacientes.

II- Que, en las actuaciones principales se le atribuye a Alcides Oscar Agostinelli Rodríguez, la comisión del siguiente hecho: "Que en fecha 10 de febrero de 2015 siendo las 18.45 horas aproximadamente, en ruta provincial N° 11 km. 165, y en ocasión en que personal de la Sección Gualeguay de Gendarmería Nacional Argentina dependiente del Escuadrón 56 "Gualeguaychú" se encontraba realizando un control físico y documentológico, se constató la tenencia por parte de Alcides Oscar Agostinelli Rodríguez de sustancia estupefaciente marihuana en la cantidad total de 6, 3 gramos conforme acta de procedimiento, como asimismo de tres pastillas de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 813/2015/2/CA1

éxtasis (MDMA- 2,3 METILENEDIOXI-N-METILANFETAMINA). Dichas sustancias estaban acondicionadas de la siguiente manera, a saber: la marihuana, contenida en un pequeño envoltorio conformado con papel de diario, en un envase de vidrio, y en un cigarrillo armado resguardado dentro de un paquete de cigarrillo marca "Marlboro"; y las pastillas, una de ellas en un envoltorio de plástico transparente, y otras dos en un envoltorio metálico, estando ubicados todos estos efectos atrás del torpedo a proximidades del cambio del rodado en el que se trasladaba, marca Volkswagen modelo Gol GL, tipo sedán 3 puertas, dominio colocado SFZ-791".

Que, a raíz de tales hechos el Juez a-quo decretó el procesamiento de Agostinelli Rodríguez por el delito de tenencia simple de estupefacientes, previsto y reprimido por el art. 14, primera parte, de la ley 23.737; resolución contra la cual se alza la defensa del imputado dando lugar a esta Instancia.

III- Que, en primer término, la defensa del imputado cuestiona el trámite procesal que ha tenido la presente causa, considerando que se ha vulnerado el derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable.



Sobre el tópico en cuestión, cabe recordar lo que la C.S.J.N. ha dicho en el precedente "Mattei": "... que la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, y que esto obedece además al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial que es el respeto debido a la dignidad del hombre, el cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona de liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito" (Fallos: 272:188).

Sentado ello, surge de la compulsa de las actuaciones principales que en fecha 02/10/2015, el Juez a-quo indagó a Agostinelli Rodríguez por la tenencia de marihuana, y decretó su procesamiento por el delito de tenencia simple de estupefacientes recién en fecha 10/02/2017; omitiéndose incluir en la plataforma fáctica las tres pastillas de éxtasis que también habían sido secuestradas en el procedimiento de fecha 10/02/2015.

Asimismo, se advierte que por resolutorio de fecha 5 de mayo de 2017, el Juez rechazó el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 813/2015/2/CA1

pedido de elevación a juicio y fijó audiencia a fin de que Agostinelli Rodríguez preste declaración indagatoria ampliatoria en la causa, en relación a las tres pastillas de MDMA (éxtasis) que también habían sido secuestradas en el evento.

A raíz de tales hechos, en fecha 18/09/2017, el Magistrado volvió a dictar el procesamiento del imputado Agostinelli Rodríguez, por tenencia simple de estupefacientes (art. 14, primera parte, de la ley 23.737), efectuando consideraciones nuevamente en torno a la tenencia de marihuana, e incluyendo ponderaciones relativas a las tres pastillas de éxtasis (cfr. fs. 1/4).

Efectuado el relato del devenir de la presente causa; cabe señalar que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas contemplado en el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica- y art. 14 inc. 3º del Pacto Internacional de Derechos Políticos y civiles, incorporados a la Constitución Nacional -art. 75 inc. 22, se encuentra razonablemente reglamentado, en nuestro derecho positivo interno, mediante el instituto de la prescripción de la acción penal, contemplado en los artículos 62 y siguientes del Código Penal; pero no obstante ello en ciertos casos (en los que las

Fecha de firma: 23/11/2017

Alta en sistema: 28/11/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30533693#194092566#20171124103740748

normas legales no resulten suficientes para resguardar debidamente el derecho en cuestión) resultará necesario tornar directamente operativo el derecho constitucionalmente reconocido.

En este orden, en principio, cuando el tiempo de tramitación de un proceso no exceda el lapso previsto en el artículo 62 del Código Penal para que opere la prescripción, no podrá considerarse vulnerado el derecho en cuestión. Tampoco ello ocurrirá cuando por alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 67 del mismo texto legal (o por otra causa legal), el término de la prescripción se vea suspendido o interrumpido.

Ha sostenido al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "el derecho del imputado a que se ponga fin a la situación de indefinición que supone el enjuiciamiento penal puede encontrar tutela en la prescripción de la acción. Como se destacó en Fallos 312:2075: "el pronunciamiento garantizador del art. 18 de la Constitución Nacional (...) puede consistir naturalmente en la declaración de prescripción de la acción penal".

En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar los agravios relativos al punto, por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 813/2015/2/CA1

considerar que el plazo del presente proceso sigue siendo razonable (art. 18 y 75 inc. 22 C.N. - Tratados Internacionales citados-).

Sin perjuicio de ello, y atento a las serias irregularidades advertidas en la tramitación de la presente causa, corresponde encomendar al Juez a-quo que en lo sucesivo, de fiel cumplimiento a los plazos procesales.

IV-a) Sentado lo expuesto, cabe referir al agravio relativo a la calificación jurídica que el sustrato merece, solicitando el defensor que sea modificada por la figura de tenencia para consumo personal -art. 14, segundo párrafo de la Ley 23.737- y que, para el caso de que el Tribunal estimara viable dicha modificación, solicita se declare su inconstitucional con fundamento en la doctrina del fallo "Arriola" de la CSJN.

Que, al respecto, este Cuerpo tiene reiteradamente sentado que en los recursos deducidos contra el auto de procesamiento la cuestión concerniente a la calificación de la conducta, atento a su provisoriedad, resulta -en principio- ajena a esta instancia.

Hemos sostenido que, "para ello, se atiende especialmente, a que... la cuestión es propia, en el caso, del llamado principio 'iura



novit curia', dado que los hechos... fueron comunicados siempre... de un modo amplio, preservando su derecho de defensa, por lo que el progreso de la causa, permitirá, en su caso, que la intimación sea rectificadora" (cfr. L.S.Crim. 2013-I-0431, entre muchos otros).

Sin perjuicio de ello, constituiría motivación suficiente para el tratamiento de la cuestión en esta instancia, si la posible revisión de la calificación jurídica pudiera tener incidencia en la modificación de una situación de privación de libertad o cuando su tratamiento pudiera dar lugar a la desvinculación definitiva del imputado de los hechos que se le reprochan, siempre que ello sea posible de realizarse en esta Alzada sin la necesidad de incorporar nuevos elementos de valoración a los ya existentes, ni que ello implique un análisis propio de la instancia de debate o juicio (cfr. voto de los Dres. Alonso y Busaniche en L.S.Crim. 2013-II-0797, entre otros).

Ello importa entonces, en este caso, exceptuar el principio general y dar tratamiento a los agravios esgrimidos por la defensa.

Sentado aquello, cabe destacar que la calificación propugnada por la defensa -art. 14, segundo párrafo de la ley 23.737- prevé una pena de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 813/2015/2/CA1

un mes a dos años de prisión cuando, por la escasa cantidad de estupefacientes y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal.

En tal sentido, cabe destacar que el acta de procedimiento refleja que el tóxico que se le secuestrara al imputado, fue habido en el interior del vehículo en el que se trasladaba, atrás del torpedo a proximidades del cambio del rodado en el que se trasladaba (cfr. 1/2 vta.), lo cual fue ratificado en sede judicial por los testigos de actuación.

Asimismo, vale referir a la cantidad de estupefaciente secuestrado -6,3 gramos de marihuana y tres pastillas de éxtasis (MDMA), pudiendo razonablemente considerarse que era escasa cantidad, tal como lo exige la figura del art. 14 segundo párrafo de la ley 23.737.

Que, además debe tenerse presente que el imputado Agostinelli Rodríguez al prestar la primera declaración indagatoria manifestó "...consumo marihuana de vez en cuando". Ello permite ser corroborado por el resultado del informe médico, en el que se concluye que es "un consumidor ocasional, alimentadas por la personalidad de base que presenta, que lo convierte en un vulnerable ante



situaciones de consumo de estupefacientes" (fs. 203/204 del principal).

Por lo expuesto, el accionar del encausado Agostinelli Rodríguez corresponde que sea encuadrado en la figura prevista en el artículo 14 segundo párrafo de la ley 23.737.

b) Que dicho ello y conforme a la calificación que se ha seleccionado para la conducta atribuida, corresponde analizar si el presente caso se adecua a la resuelto por la C.S.J.N. en la causa "Arriola", de fecha 25 de agosto del año 2.009, por el cual ha declarado la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 14 de la ley 23.737.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa referida (Fallo A 891 XLIV) con remisión a los fundamentos dados en "Bazterrica" (Fallos 308: 1392), declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 "pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales", - ... - "en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros..." (Consid. 36 de "Arriola");





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 813/2015/2/CA1

Argumentó también el Alto Tribunal que los consumidores de drogas, en especial cuando se transforman en adictos, son las víctimas más visibles -junto a sus familias- del flagelo del narcotráfico; por lo cual, no parece irrazonable sostener que una respuesta punitiva del Estado al consumidor se traduzca en una revictimización y reitera la necesidad de combatir el tráfico de drogas, no a través de la persecución penal de sus propias víctimas -es decir los consumidores- sino de los distribuidores. Agregó, que si bien como principio, lo referente al mejor modo de perseguir el delito y cuáles son los bienes jurídicos que requieren mayor protección, constituyen cuestiones de política criminal propias de otras esferas del Estado, lo cierto es que allí se trataba de la impugnación de un sistema normativo que criminaliza conductas que -realizadas bajo determinadas circunstancias- no afectaban a un tercero y, por lo tanto están a resguardo del artículo 19 de la Constitución Nacional. Siguiendo ese razonamiento, entendió que el Congreso había sobrepasado las facultades que le otorgaba la Carta Magna.

En ese marco, con esos límites y conforme las circunstancias en que se produjo el hallazgo del material estupefaciente -oculto en el torpedo del



vehículo, cercano a la palanca de cambios-, y a los dichos del propio imputado quien señaló que: "... Rodrigo no sabía nada. Él no consume... Paramos en una estación de servicios... baja él y yo tenía esto en mi mochila, lo quise esconder mejor y lo puse atrás de la palanca de cambio, sería en la parte del cenicero, abajo..." lo que se condice con lo manifestado por el conductor Ali -quien señaló que desconocía la existencia del tóxico en su rodado- (cfr. indagatoria obrantes en sistema Lex100); es dable concluir que la tenencia reprochada no trajo aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros, por lo que el hecho es asimilable al que diera lugar a la doctrina judicial sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos referidos.

Por lo expuesto corresponde por imperio de la autoridad institucional de las pautas del más alto cuerpo judicial de la República, declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 14 de la ley 23.737, y en consecuencia sobreseer a Acides Oscar Agostinelli (cfr. art. 336 C.P.P.P.N.).

La **Dra. Cintia Graciela Gomez**, dijo: I-..., II-..., III-..., IV- Que los agravios de la Defensa se dirigen principalmente a cuestionar la subsunción jurídica del hecho que efectuara el Sr. Juez *a quo*,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 813/2015/2/CA1

entendiendo que debe mutarse la calificación por la del segundo párrafo del art. 14 de la ley 23737, es decir para consumo personal y colegirse de ello la desvinculación de su defendido del proceso, en base a las pautas del precedente "Arriola".

Que sobre este tema, he reiteradamente sentado que en los recursos deducidos contra el auto de procesamiento la cuestión concerniente a la calificación de la conducta, atento a su provisoriedad, resulta -en principio- ajena a esta instancia.

Y que, *"para ello, se atiende especialmente, a que... la cuestión es propia, en el caso, del llamado principio 'iura novit curia', dado que los hechos... fueron comunicados siempre... de un modo amplio, preservando su derecho de defensa, por lo que el progreso de la causa, permitirá, en su caso, que la intimación sea rectificadora"* (cfr. L.S.Crim. 2013-I-0431, entre muchos otros).

Sin embargo, he dicho también que si la revisión de la calificación jurídica tuviera alguna incidencia en la modificación de una situación de privación de libertad, ello constituiría motivación suficiente para dar tratamiento a la cuestión en esta instancia.



En el caso, la eventual mutación de la figura penal endilgada al imputado carece de entidad para excepcionar dicha regla, atento la situación de hecho -libertad- en la que aquel se encuentra.

En efecto, la circunstancia de que el sustrato fáctico fuera correctamente comunicado (cfr. declaración obrante en Sistema Lex 100), viabiliza la eventual revisión de la calificación legal de su intervención en el momento procesal correspondiente, salvaguardando el derecho de defensa y, paralelamente, asegurando el principio de congruencia.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmar la resolución apelada.

El **Dr. David Alejandro Chaulet**, dijo: Que, adhiero al voto del Dr. Alonso.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, por mayoría, **SE RESUELVE:**

I-Encomendar al Juez a-quo lo expuesto en el considerando III- de la presente resolución.

II- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Alcides Oscar Agostinelli Rodríguez y en consecuencia, al cambio de calificación solicitado, encuadrando el accionar





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 813/2015/2/CA1

del nombrado en la figura prevista por el artículo 14 segundo párrafo de la ley 23.737.

III- Declarar la inconstitucionalidad del art. 14 segundo párrafo de la ley 23.737.

IV- Dictar el sobreseimiento de Alcides Oscar Agostinelli Rodríguez, cuyos demás datos de identidad obran en autos, en orden al delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal (art. 14 2do. Párrafo de la Ley 23.737), de conformidad con lo prescripto por el artículo 336 y ccdtes. del C.P.P.N., haciendo expresa mención que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor del que el nombrado gozare.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ
EN DISIDENCIA

DANIEL EDGARDO ALONSO

DAVID ALEJANDRO CHAULET

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

